刑法11 筆記：著手理論

> 來源：刑法11 課程字幕 01:01:00 ~ 01:41:00

🕮 法條原文速查

> **§25 I**（未遂犯定義）
> 已**著手**於犯罪行為之實行而不遂者，為未遂犯。

> **§221**（強制性交罪）
> 對於男女以**強暴、脅迫**、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者…

> **§222 I**（加重強制性交罪）
> 犯前條之罪而有下列情形之一者，處七年以上有期徒刑：
> 第四款：以藥劑犯之者。→ 使用藥劑本身就是§221的「強暴」
> → 加重構成要件**不影響**著手認定，一律回歸基本構成要件

> **§321**（加重竊盜罪）
> 犯竊盜罪而有下列情形之一者…
> → 侵入住宅僅為加重構成要件，著手回歸§320 判斷

> **§339-4**（加重詐欺罪）
> → 加重構成要件，著手回歸§339

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「著手的通說為何？」	**主客觀混合說**：以行為人主觀犯罪計畫為判斷對象，以一般人標準判斷有無法益迫切危險
「主客觀混合說與實質客觀說差異？」	**判斷對象不同**：實質客觀說看客觀事實，主客觀混合說看行為人犯罪計畫
「形式客觀說為何被放棄？」	對著手認定**過嚴**，不利法益保護；但「已做構成要件行為＝著手」的原則仍保留
「加重構成要件能否判斷著手？」	**不能**。一律回歸**基本構成要件**判斷著手
「隔離犯如何判斷著手？」	三說：**嚴格個別理論**（做完就著手，實務傾向）；修正個別理論；**嚴格整體理論**（許恆達採）
「不遂的涵蓋範圍？」	客觀構成要件六格**任一**未實現即為未遂（不限於「結果未發生」）
「結果提前發生與著手的關係？」	結果提前發生案例中，須判斷行為人是否已跨入**著手階段**→ 影響能否論故意殺人未遂

正文

一、著手認定的學說

（一）形式客觀說（歷史上的說法）

- 主張：行為人開始做**嚴格意義的構成要件行為**才算著手
- 優點：標準明確
- 缺點：認定**過嚴**，不利法益保護
- 現況：幾乎無人採，但「有做構成要件行為→原則上著手」的基準仍被保留

（二）實質客觀說（行為危險說）

- 主張：行為人做到讓法益有**迫切危險**的階段，即為著手
- 判斷對象：純粹的**客觀事實**
- 例：殺人罪（槍殺）→ 瞄準即著手（不用到扣板機）

（三）主觀說（歷史上的說法）

- 主張：看行為人**自覺**何時開始→ 幾乎無人採（技術上難判斷）

（四）主客觀混合說（通說）

- 區分**判斷對象** vs. **判斷標準**：

面向	內容
判斷對象（主觀面）	行為人腦中的**犯罪計畫**
判斷標準（客觀面）	從一般人角度看，做到此階段是否對法益有**迫切危險**

```
主客觀混合說（通說）
│
├── 判斷對象 → 行為人主觀犯罪計畫（主觀面）
│
└── 判斷標準 → 一般人角度：有無法益迫切危險（客觀面）
                        ↓
                  與實質客觀說標準相近
                  差別在判斷「對象」不同
```

各說在不能未遂案例的差異

> **案例**（甘添貴老師）：臺灣人在花蓮七星潭，持手槍朝東邊開槍，確信子彈可橫越太平洋打死美國西岸的人。

學說	有無著手	理由
實質客觀說	**無**（找不到著手時點）	手槍射程幾百公尺，客觀上對任何人無威脅
主客觀混合說	**有**	假設犯罪計畫可實現→扣板機即著手

二、著手認定的具體案例分析

（一）已做構成要件行為 → 原則著手

- 雖然形式客觀說被放棄，但已做構成要件行為 → 原則上仍認為著手
- 例外：隔離犯、加重構成要件等特殊情形

案例：104年判決（§227 著手）

事實

1. 成年男子與國中女友相約在女方家性交
2. 進入房間後未鎖門，僅關門
3. 雙方親吻、愛撫、脫衣、男方戴上保險套
4. 男方生殖器距女方陰道約三公分時，女方弟弟開門

分析

- 法院認定：套上保險套、距陰道約三公分 → 與性交具有**直接密切關聯** → 已**著手**
- 不需到外陰部摩擦的階段

（二）隔離犯的著手

定義：行為人做完犯罪行為到犯罪實現，中間需**間隔時間、空間**，或需**被害人配合**。

典型案例：定時炸彈、在飲食中下毒、攔截賽鴿

學說	主張	嚴格程度
嚴格個別理論	做完行為就著手（不論間隔多久）	最**寬鬆**（實務傾向）
修正個別理論	做完行為＋行為人**回頭來不及**時才著手	中間
嚴格整體理論	要**被害人端**也進入法益迫切危險才著手	最**嚴格**（許恆達老師採）

> **補充**：隔離犯的著手理論 = 間接正犯的著手理論（許恆達老師的文章已二次使用）

案例：臺北車站定時炸彈

事實

- 行為人在行李箱內裝30分鐘定時炸彈，放在臺北車站，隨後搭高鐵離開

各說分析

學說	結論	理由
嚴格個別理論	裝完即著手	做完就算
修正個別理論	跳上不停板橋的高鐵時著手	到桃園再回來至少40分鐘→回頭來不及
嚴格整體理論	快爆炸時才著手	之前仍可能被發現推開

（三）加重構成要件不影響著手認定

通說：加重構成要件開始實行 ≠ 著手。一律**回歸基本構成要件**判斷。

案例	表面上看起來	實際認定
從頂樓垂降到陽臺欲性侵（§222）	開始做加重要件（侵入住宅）	未著手§222（須回歸§221判斷）
入侵住宅物色財物竊盜（§321）	開始做加重要件（侵入住宅）	**已著手**→但非因§321，而是回歸§320，進入住宅搜尋財物→財產有迫切危險
用藥劑性侵（§222 I④）	開始下藥	**已著手**→但非因§222，而是使用藥劑本身就是§221的「強暴」

> **總歸一句**：加重構成要件與著手判斷**完全無關**。即使剛好在做加重構成要件時認定著手，也是基本構成要件使然。

（四）實質客觀說 vs. 主客觀混合說的差異案例

一般情形：實質客觀說對行為人較有利，主客觀混合說較不利。

但有例外：

案例：安眠藥 vs. 毒藥誤拿

事實

- 甲計畫用安眠藥迷昏A，再持刀刺死A
- 甲拿安眠藥時誤拿毒藥，造成A中毒（未死）

分析

學說	有無著手	理由
實質客觀說	**有**	客觀上拿的是毒藥→對法益有迫切危險
主客觀混合說	**無**	行為人犯罪計畫：安眠藥迷昏→再用刀→距離殺人還很遠

> 此案例涉及**結果提前發生**問題。若採主客觀混合說認為未著手→只能論**過失致死**。

三、不遂要件

- 客觀構成要件六格（主體、客體、行為、結果、因果關係、情狀）**任一**未實現 → 即為未遂
- ⚠ 不要以為只有「結果未發生」才叫未遂

未遂類型	案例
客體不存在	屍體以為是活人而開槍
行為客體錯誤	偷別人的傘，發現是自己的
行為未完成	砍人但被閃過
結果未發生	開槍未命中

四、普通未遂的法律效果

- 符合四大要件（故意、著手、不遂、明文）→ **普通未遂**
- 效果：**得按既遂犯之刑減輕之**（可減可不減）
- 舊稱「障礙未遂」（日語用語），現在學界多用「普通未遂」

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§25	未遂犯	著手＋不遂定義
§221	強制性交罪	基本構成要件（判斷§222著手）
§222	加重強制性交罪	加重構成要件不影響著手判斷
§321	加重竊盜罪	加重構成要件不影響著手判斷
§320	竊盜罪	回歸基本構成要件判斷著手
§339-4	加重詐欺罪	加重構成要件不影響著手判斷

關鍵學者文獻速查表

學者	文章	主題
蔡聖偉	〈惡視力〉	著手理論，主客觀混合說與不能未遂
許恆達	隔離犯著手 + 錯誤支配	個別理論 vs. 整體理論（傾向嚴格整體理論）